# DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

**NRO. DE EXPEDIENTE** : EXP. NRO. 04-2022-RAFC-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/ AYA.

**MODALIDAD DE ARBITRAJE** : Arbitraje de Emergencia.

**PARTES INTERVINIENTES** :

**Demandante :** Terrasoft Contratistas S.A.C

**Demandado :** Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca

**ARBITRO DE EMERGENCIA** : Abg. Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas.

**SECRETARIA ARBITRAL** : Abg. Rosnery Gladis Domínguez Quispe.

**PEDIDO CAUTELAR** : Medida Cautelar de No Innovar

**INICIO DE LA SOLICITUD** : 25 de mayo de 2022.

**FECHA DE CONCLUSION** : 02 de junio de 2022.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

**CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD**

Caso Arbitral N°04-2022-RAFC-CA-CECARD/ARBITRAJE DE EMERGENCIA/AYA

TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C.

*v.*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA

---

# RESOLUCIÓN CAUTELAR

---

*Árbitro de Emergencia*
Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas

*Secretaria Arbitral*
Rosnery Gladis Domínguez Quispe

Ayacucho, 02 de junio de 2022

Ayacucho, 02 de junio de 2022

ÍNDICE


I. TABLA DE ABREVIATURAS ..... 3
II. PARTES DEL EXPEDIENTE CAUTELAR ..... 4
III. CONVENIO ARBITRAL ..... 4
IV. ANTECEDENTES DE LA MEDIDA CAUTELAR ..... 5
V. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR ..... 8
VI. ABSOLUCIÓN DE TRASLADO Y OPOSICIÓN DE LA ENTIDAD ..... 15
VII. ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA ..... 15
VIII. DECISIÓN ..... 41

## I. TABLA DE ABREVIATURAS

| TÉRMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE DECISIÓN | |
|---|---|
| SOLICITANTE o CONTRATISTA | TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C. |
| ENTIDAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA |
| PARTES | TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C. y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA |
| CENTRO | CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD |
| ÁRBITRO DE EMERGENCIA | RODRIGO ANDRÉS FREITAS CABANILLAS |
| CONTRATO | CONTRATO Nº 097-2020-MDSL/GM |
| LCE | LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADA POR LA LEY 30225, Y MODIFICADA POR DECRETO LEGISLATIVO N° 1444 |
| RLCE | REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF |

# RESOLUCIÓN CAUTELAR Nº 5

En la ciudad de Ayacucho, a los 02 (dos) del mes de junio del año 2022, el Árbitro de Emergencia (en lo sucesivo, el **Árbitro**), luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD (en lo sucesivo, el **Centro**) y, habiendo proporcionado derecho de contradicción y trato de igualdad a las partes en el presente procedimiento, el Árbitro dicta la presente resolución cautelar:

## II. PARTES DEL EXPEDIENTE CAUTELAR

1. **TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C.**, con RUC Nº 20495171494, (en lo sucesivo, el **CONTRATISTA** o **SOLICITANTE**), con domicilio para estos efectos en Urb. Luis Carranza Mz D lote 26, departamento de Ayacucho.

2. **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA,** con RUC Nº 20213832361, (en lo sucesivo, la **ENTIDAD** o **MUNICIPALIDAD)** representada por el Alcalde, el señor Ober Curitomay Quispe, con domicilio para estos efectos en la Plaza Principal S/N Lucanamarca – Huancasancos – Ayacucho.

## III. CONVENIO ARBITRAL

3. El convenio arbitral que ampara la presente solicitud de medida cautelar se encuentra contenida en la Cláusula Vigésima del Contrato Nº 097-2020-MDSL/GM para la ejecución de la obra: "*Creación de pistas veredas en los jirones Jr. Compañía, Jr. 28 de julio, Jr. Grau, Jr. Bolívar, Jr. 11 de junio, Jr. Brasil, Jr. los Chankas y Jr. Porvenir en la localidad de San José de Huarcaya del distrito de Santiago de Lucanamarca – Huanca Sancos – Ayacucho*"." en los siguientes términos y alcances:

> "*SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la ley de contrataciones del estado y su reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, sin perjuicio*

*de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.*
*El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado*".

## IV. ANTECEDENTES DE LA MEDIDA CAUTELAR

### 1.1. Inicio

4. Mediante escrito presentado el 25 de mayo del 2022, el Contratista formuló una solicitud consistente en una medida cautelar para ser tramitada y decidida por un Arbitraje de Emergencia.

5. En dicha solicitud el Contratista solicita que el Árbitro conceda la medida cautelar de no innovar cuya finalidad consiste, de acuerdo con lo que expresamente señaló, en que la Municipalidad se abstenga de ejecutar la CARTA FIANZA N° 220301643-R5, por el importe de S/ 397, 563.94 (Trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta y tres con 94/100 soles), otorgada para el perfeccionamiento del Contrato.

6. Asimismo, a través de la solicitud cautelar presentada el 25 de mayo de 2022, el Contratista, solicitó al Árbitro de Emergencia que su pedido de medida cautelar sea resuelto *inaudita par*s, esto debido a que la Entidad podría tomar medidas que perjudiquen lo solicitado.

### 1.2. Designación del Árbitro de Emergencia

7. Mediante Carta de fecha 25 de mayo de 2022, la Secretaria General del Centro comunicó al abogado Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas, identificado con DNI N° 46625467, su designación en calidad de Árbitro de Emergencia.

8. El 26 de mayo de 2022, el abogado Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas, aceptó el cargo de Árbitro de Emergencia y presentó su Declaración de Independencia, Imparcialidad y Disponibilidad.

## 1.3. Antecedentes de las actuaciones arbitrales

### Resolución Cautelar Nº 1

9. Mediante Resolución Nº 01, emitida el 26 de mayo de 2022, el Árbitro realizó una ponderación de derecho y de los principios en juego, por la cual resolvió lo siguiente:

> "***PRIMERO: CORRER TRASLADO*** *a la* ***MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAMARCA*** *del escrito cautelar presentado por* ***TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C.*** *el 25 de mayo de 2022, a fin de que en un plazo de dos (2) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificado con la presente Resolución, manifieste lo que estime corresponder en defensa de sus derechos.*
>
> ***SEGUNDO: ORDENAR*** *que la* ***MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAMARCA****, hasta que el Árbitro de Emergencia emita una decisión sobre el pedido cautelar presentado, se abstenga, de requerir a* ***INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS****, la ejecución de la Carta Fianza Nº 220301643-R5 por el monto de S/. 397,563.94 (Trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta y tres con 94/100 soles) correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento, emitida a favor* ***de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAMARCA.***
>
> ***TERCERO: PRECISAR*** *que la Orden Procesal contenida en la presente Resolución no constituye un adelanto de opinión del Árbitro de Emergencia ni el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por* ***TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C.***
>
> ***CUARTO: NOTIFICAR*** *la presente Resolución a* ***INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS****, a fin de que tome conocimiento de la medida cautelar solicitada por* ***TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C.*** *y las reglas que está estableciendo el Árbitro de Emergencia respecto del trámite de la solicitud cautelar.*"

**Resolución Cautelar Nº 2**

10. Mediante Resolución Nº 02, emitida el 26 de mayo de 2022, el Árbitro de Emergencia realizó una corrección de un error material respecto de la denominación de la Entidad en la Resolución Cautelar N° 01, por la cual resolvió tener por denominación correcta de la Entidad como "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA".

11. En esa misma línea, el Árbitro de Emergencia, también resolvió notificar la precitada Resolución Cautelar a las Partes como a la empresa INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS.

**Resolución Cautelar Nº 3**

12. Mediante escrito Nro. 01 de fecha 27 de mayo de 2022, el Contratista hace de conocimiento del Árbitro de Emergencia que INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo del presente, les señala: "*Muchas gracias por la información, sin embargo, la Resolución remitida no constituye una medida cautelar*", lo cual, para el Consorcio, constituiría una manifestación de no estar dispuesto a cumplir con la orden procesal de abstenerse a ejecutar la carta fianza.

13. Es así que, mediante Resolución Nº 03, emitida el 27 de mayo de 2022, el Árbitro de Emergencia resolvió ordenar a INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS no ejecutar la Carta Fianza N.º 220301643-R5 por el monto de S/. 397,563.94 (Trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta y tres con 94/100 soles), mientras el Árbitro de Emergencia resuelva la solicitud de medida cautelar, bajo responsabilidad de su titular o representante legal.

**Resolución Cautelar Nº 4**

14. Mediante Resolución Nº 04, emitida el 31 de mayo de 2022, el Árbitro de Emergencia resolvió tener presente la Razón de Secretaria de fecha 26 de mayo del 2022, la misma que demuestra que la Entidad ha sido debidamente notificada con las actuaciones del Árbitro y se dejó constancia que la Entidad no cumplió con pronunciarse respecto de la medida cautelar pese a estar válidamente notificado.

15. Asimismo, se dispuso el plazo de dos (02) días hábiles a fin de que el Árbitro de Emergencia resuelva el pedido cautelar.

16. Según lo reseñado, puede observarse que ambas partes han tenido la oportunidad para manifestar lo conveniente a su derecho, de conformidad con las reglas a las que se han sometido de acuerdo con su convenio arbitral.

17. En consecuencia, corresponde al Árbitro analizar los fundamentos de la solicitud de medida cautelar formulada por el Contratista frente a la Entidad, así como los argumentos que sustentan la absolución a la misma presentada por la Entidad y, finalmente, emitir pronunciamiento.

## V. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

18. El 25 de mayo de 2022, el Contratista, formuló una solicitud consistente en una medida cautelar de no innovar para ser tramitada y decidida en un Arbitraje de Emergencia, en mérito del cual formuló la pretensión que se transcribe a continuación:

> *"PRETENSIÓN CAUTELAR DE NO INNOVAR: En protección del legítimo derecho de TERRASOFT CONTRATISTAS SAC, en el proceso Arbitral a instaurarse y al amparo del inciso b) del artículo 63 del Reglamento de Arbitraje de Centro de Arbitraje - CECARD y el artículo 47 de la Ley General de Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 1071; SOLICITAMOS DICTE MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN: ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA A QUE SE ABSTENGA A EJECUTAR:*
> *(i) La CARTA FIANZA Nº 220301643-R5, emitida por INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, por el importe de S/. 397,563.94 (Trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta y tres con 94/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del contrato Nº 097-2020-MDSL/GM.*
> *En consecuencia, se curse oficio a la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca, con domicilio en la Plaza Principal S/N Lucanamarca – Huancasancos – Ayacucho; así como a INSUR COMPAÑÍA DE SEGUROS, con sede en Av. Pardo y Aliaga Nº 699, oficina Nº 302. San Isidro – Lima."*.

19. De forma preliminar, el Contratista, manifestó que, el 30 de setiembre de 2020, las partes suscribieron el Contrato Nro. 097-2020-MDSL/GM, que tiene por objeto la contratación de Ejecución de la Obra: "Creación de Pistas Veredas en los Jirones Jr. Compañía, Jr. 28 de Julio, Jr. Grau, Jr. Bolívar, Jr. 11 de junio, Jr. Brasil, Jr. Los Chankas

y Jr. Porvenir en la Localidad de San José de Huarcaya del Distrito de Santiago de Lucanamarca – Huancasancos-Ayacucho" (en adelante, Contrato).

20. Subsiguientemente, el solicitante, señaló que, con Carta Nro. 038-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL de fecha 01 de diciembre de 2021, el Contratista requirió a la Entidad el pago de las valorizaciones Nro. 01, 02 y 03 correspondientes al adicional de Obra Nro. 01 que ascienden al monto de S/. 422, 420.48 soles (cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte con 18/100 soles).

21. Bajo esta tesitura, el Contratista, arguyó que, vencido el plazo otorgado a la Entidad para efectivizar el pago de las valorizaciones Nro. 01, 02 y 03 correspondientes al adicional de Obra Nro. 01, en atención a lo dispuesto en el artículo 164.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el RLCE), el Contratista procedió a resolver el Contrato Nro. 097-2020-MDSL/GM, mediante Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, notificada a la Entidad el 21 de diciembre de 2021.

22. Es así que, el Contratista señala que, la resolución del contrato efectuada por él no fue objetada por la Entidad dentro del plazo previsto en el artículo 166.3 del RLCE, lo que deriva en el consentimiento de este acto. Además, aclara que la fecha límite para controvertir la resolución del contrato era el 07 de febrero del 2022.

23. En ese mismo sentido, el solicitante, afirmó que, en fecha posterior, el 06 de enero del 2022, y como efecto de la resolución del contrato se procedió a realizar la constatación e inventario de la obra, quedando así entregada a la Entidad por efecto de lo dispuesto en el artículo 207.3 del RLCE.

24. Asimismo, el Contratista, alegó que, el 11 de febrero de 2022, mediante Carta Notarial S/N, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el contrato aun cuando el contrato había sido ya resuelto por el Contratista y la resolución había sido consentida por la Entidad.

25. Continuando con sus argumentos, el Contratista, refirió que, el 14 de febrero de 2022 mediante Carta Nº 014-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL el Contratista presentó ante la Entidad la liquidación del contrato de obra que arrojó un saldo a su favor de S/ 706,946.03 (setecientos seis mil novecientos cuarenta y seis con 03/100 nuevos soles). Además, el Contratista aclaró que, en el período en que la liquidación de obra era revisada por la Entidad se produjo el pago de S/. 100,00.00 (cien

mil con 00/100 soles), por lo que el saldo a favor del Contratista ascendería a S/. 606,946.03 (seiscientos seis mil novecientos cuarenta y seis con 03/100 nuevos soles).

26. En este orden de ideas, el Contratista, sostuvo que, el 21 de marzo de 2022 mediante Carta Nº 008-2022-MDSL/A la Entidad remitió las observaciones a la liquidación de obra, y a través de la Carta Nº 019-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, donde el Contratista manifestó estar conforme con las observaciones. Además, precisó que la liquidación no fue observada por deficiencia en los cálculos efectuados ni respecto del saldo a favor del Contratista sino porque esta no cumplía con los parámetros de ficha de requerimiento de liquidación.

27. De modo semejante, el solicitante, manifestó que, el 19 de abril de 2022 mediante carta Nº 021-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, el Contratista manifestó a la Entidad que la liquidación había quedado consentida por efecto de lo dispuesto en el artículo 209.6 del RLCE, solicitando el pago del saldo a favor y la devolución de las cartas fianzas.

**a. Sobre la Fundabilidad de la Medida Cautelar solicitada**

28. El Contratista comienza señalando que el 11 de febrero de 2022, mediante carta Notarial S/N, la Entidad comunicó al Contratista su decisión de resolver el contrato, pero ese acto resultaría ineficaz y/o inválido debido a que la resolución del contrato que efectuara el Contratista fue consentida por la Entidad, consentimiento que se produjo el 07 de febrero de 2022.

29. En esa línea de argumentación, el Contratista señala que su resolución del Contrato fue consentida por la Entidad, y que la misma igual decidió ejecutar la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato, decisión que se plasmó en la Carta Notarial S/N enviada a INSUR - partner of atradius, remitida el 24 de mayo de 2022. Siendo de esa manera, señala el Contratista, en la comunicación enviada al emisor de la carta fianza se verifica que la ejecución se produce ante la resolución del contrato.

30. En consecuencia, el Contratista alega que la Entidad pretende la ejecución de la carta fianza aun cuando no sometieron a controversia la resolución del contrato realizada por él, aun cuando la liquidación quedó aprobada por la Entidad y contiene un saldo a favor del Contratista que asciende a S/ 606,946.03 (seiscientos seis mil novecientos cuarenta y seis con 03/100 nuevos soles).

31. En ese sentido, el Contratista alega que, respecto de la liquidación, su aprobación y el saldo a favor que contiene esta, aclara que: i) Mediante CARTA N°014-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, de fecha 14 de febrero del 2022, el Contratista presentó la liquidación de obra que fue observada mediante CARTA N°008-2022-MDSL/A; ii) Mediante CARTA N°192022- TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, el Contratista remite la Liquidación de Obra acogiendo las observaciones realizadas por la Entidad; iii) Mediante CARTA N°021-2022-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, el Contratista manifestó a la Entidad que la liquidación había sido aprobada y solicitó el pago del saldo a su favor que asciende a S/. 606,897.04 (seis cientos seis mil ochocientos noventa y siete con 04/100 soles) y la devolución de las cartas fianzas de fiel cumplimiento: N°220301643, N°220301643-R1, N°220301643-R2, N°220301643-R3, N°220301643-R.

32. Finalmente, el Contratista refuerza su argumento señalando que el art. 155 del RLCE, establece que la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento sería posible de por la no renovación, no siendo ese el caso, puesto que la carta fianza se encuentra vigente o, en similar caso, si la resolución del contrato efectuada por la Entidad se hubiera consentido, supuesto que no se aplicaría en el presente caso, ya que la resolución por la Entidad sería ineficaz y/o inválida debido al consentimiento de la resolución efectuada por él.

**b. Sobre la verosimilitud del derecho invocado**

33. Sobre este requisito, el Contratista, sostuvo que, si bien se aconseja un análisis minucioso de los presupuestos, la normativa no impone una verosimilitud recargada o presencia cercana a la certeza. La verosimilitud exigida a la prohibición de innovar, sostiene el Contratista, no se equipará a una incuestionable realidad, sino que alcanza con que satisfaga el marco de lo hipotético y razonable. La verosimilitud en la medida cautelar de prohibición de innovar, agrega el Contratista, se vincula al ámbito de lo hipotético y razonablemente posible.

34. Asimismo, el Solicitante alega que, la controversia gira en torno a la validez y/o ineficacia de la resolución del contrato efectuada por la Entidad.

35. Además, el Contratista sostiene que, la Resolución del Contrato efectuada fue notificada el 21 de diciembre de 2021; por lo que, de conformidad con el artículo 166° del RLCE, la Entidad tenía plazo perentorio de 30 días para iniciar un procedimiento de conciliación o de arbitraje; plazo que tenía como fecha de vencimiento el 07 de febrero de 2022, y que a la fecha no existiría procedimiento arbitral alguno.

36. En consecuencia, sostiene el Contratista, el derecho que tendría la Entidad de cuestionar la validez legal de la Resolución del Contrato efectuada por el Contratista habría caducado; habiendo quedado consentida la resolución del contrato efectuada mediante Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, de fecha 21 de diciembre de 2021.

37. Por lo tanto, alegal Contratista, el derecho invocado es verosímil, pues el derecho de la Entidad de cuestionar la validez de la Resolución del Contrato, realizada por el Contratista, habría caducado, debido a que, hasta el 07 de febrero de 2022, y aun después, no se cuestionó la resolución del contrato efectuada por el Solicitante. Además, arguye el Solicitante, el derecho es verosímil, puesto que la resolución del contrato efectuada por la Entidad se realiza el 11 de febrero de 2022, fecha para la cual la resolución efectuada por el Contratista no podía ya cuestionarse por haber quedado consentida.

**c. Sobre el peligro en la demora y perjuicio irreparable**

38. El Contratista sostiene que, Carta Fianza N° 220301643-R5 tiene la naturaleza de solidaria, irrevocable, incondicional, indivisible y de realización automática; siendo que esta puede ser ejecutada en cualquier momento. Por lo tanto, el peligro en la demora radicaría esencialmente en la posibilidad que tiene la Entidad de ejecutar la Carta Fianza N° 220301643-R5, a pesar de que la resolución del Contrato es por causas imputables únicamente a la Entidad. Esto, por cuanto la referida Carta Fianza tiene como finalidad garantizar el fiel cumplimiento del contrato; entonces, al haberse resuelto el contrato por causas imputables a la Entidad, el Contratista quedaría liberado de sus obligaciones; asimismo, la Entidad no tendría derecho alguno a ejecutar la referida Carta Fianza, pues la resolución del Contrato obedecería única y exclusivamente al actuar de la Entidad.

39. En esa línea, señala el Contratista, la referida Carta Fianza tiene como finalidad garantizar el fiel cumplimiento del contrato; entonces, al haberse resuelto el contrato por causas imputables a la Entidad (como se habría sustentado, el incumplimiento del pago de 3 valorizaciones), el Contratista quedaría liberado de sus obligaciones

40. Asimismo, señala la Entidad, la ejecución de la Carta Fianza N° 220301643-R5 constituye un ejercicio abusivo del derecho que debe ser cautelado; pues, la Entidad no solo habría incumplido sus obligaciones esenciales, sino que además al pretender la

ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, se pretendería también responsabilizar del Contratista por la Resolución del Contrato.

41. Por otro lado, el Contratista refuerza su postura señalando que, la doctrina nacional señala que para la imposición de una medida cautelar se requiere que el peligro en la demora sea posible y cierto, más no así inminente. Sin embargo, añade el Contratista, para la medida cautelar de no innovar requiere de la existencia de una situación especial. Así, el Contratista cita lo señalado en el Código Procesal Civil, art. 687°: "*Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o sea invocada en la demanda y bienes comprendidos en el proceso. Esta medida es excepcional por lo que se concederá sólo cuando no resulte de aplicación otra vista en la ley.*"

42. Concluyendo así, el Contratista, que se requiere la existencia de un peligro irreparable lo que en el presente caso concurre y además es un peligro inminente, por cuanto en la Carta Notarial S/N de fecha 24 de mayo de 2022 se solicita la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento.

43. En conclusión, alega el Contratista, que durante la tramitación del proceso arbitral la Entidad podrá ejecutar la Carta Fianza N° 220301643-R5; lo que causaría un perjuicio irreparable al Contratista.

**d. Sobre la Proporcionalidad y Adecuación de la Medida**

44. Sobre este punto, el Contratista, manifestó que, la medida cautelar de no innovar es proporcional, por cuanto se busca cautelar la no ejecución de la Carta Fianza N° 220301643-R5 que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato N° 097-2020-MDSL/GM; esto, derivado del futuro proceso arbitral que busca la ineficaz de la Resolución del Contrato efectuado por la Entidad.

45. Entonces, señala el Contratista, el fin que se busca es cautelar el derecho patrimonial del Contratista, que se vería perjudicado ante la ejecución de la Carta Fianza N° 220301643-R6.

46. En ese sentido, el Contratista alega que, el medio que debe ser empleado para cautelar dicho fin, es la conservación de la situación de hecho y de derecho que existe actualmente; esto es, la vigencia de la Carta Fianza N° 220301643-R5, y la eficacia de la Resolución del Contrato hecha por el Contratista.

47. El Contratista, alegó que, la medida cautelar de no innovar es la más adecuada, pues es precisamente la que tiene la naturaleza de conservar la situación de hecho y de derecho, siendo esta, en comparación con otras medidas, la única que podría tener eficacia para el fin que se busca.

48. Concluyendo, el Contratista alega que, el derecho que se afectaría es el que tiene la Entidad de ejecutar las cartas fianza ante incumplimientos por parte del Contratista; sin embargo, ese derecho ya habría caducado, pues la Entidad habría consentido la Resolución del Contrato efectuada por el Contratista. Entonces, señala el Contratista, la afectación que sufrirá la Entidad es nula, pues su propio acto (consentir la Resolución del Contrato) conlleva a que no tenga derecho a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento. Además, precisa el Contratista, si en la liquidación de obra se ha determinado un saldo a favor del Contratista ya no tiene objeto mantener vigente la carta fianza, porque así lo dispone el artículo 149.2 del RLCE. Por lo tanto, finaliza el Contratista, la medida cautelar solicitada sería proporcional y adecuada.

**e. Entidad encargada de la ejecución de la Medida Cautelar**

49. El Contratista sostuvo que, la Carta Fianza N° 220301643-R5 fue emitida por una Compañía de seguros, por tanto, sería necesario que sea ella quien ejecute la medida cautelar. En ese sentido, solicitó que se curse oficio a "INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS", con domicilio fiscal en la Av. Pardo y Aliaga N° 699 – Oficina 302, del distrito de San Isidro, provincia de Lima; y con número telefónico (511) 616 4141.

**f. Sobre la Contracautela**

50. El Contratista alegó que, a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 60 y 64 del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje - CECARD, ofrecemos contracautela en la forma de Caución Juratoria hasta por el monto de S/. 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles). Sin embargo, dejamos a criterio del Tribunal la decisión de exigir otra contracautela en la forma que estime adecuada.

**g. Sobre la Tramitación de la Medida Cautelar sin conocimiento de parte**

51. El Contratista, refirió que, en nuestro ordenamiento jurídico las medidas cautelares se tramitan y se resuelvan *inaudita altera parte*, es decir, sin oír al sujeto pasivo de la medida cautelar. Debido a que, si el sujeto pasivo toma conocimiento de la intención de la parte activa de obtener una medida cautelar, podrá adoptar todas aquellas acciones a efectos de frustrar la eficacia de dicha medida.

52. Siendo el caso que, señala el Contratista, el Tribunal resuelva el pedido cautelar sin que se ponga en conocimiento del mismo a la Entidad, pues de lo contrario, INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS ejecutará la carta fianza y lo pondrá a disposición de la Entidad; en consecuencia, tornará estéril o absolutamente ineficaz el laudo que oportunamente se expedirá.

53. Además, continúa, el Contratista, la base legal de la tramitación de la medida cautelar sin conocimiento de la parte pasiva se encontraría en el artículo 637 del Código Procesal Civil.

54. Es así que, alegal Contratista, coherentemente con lo que se dispone en el ámbito del proceso civil, el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje (CECARD) señala que el Tribunal Arbitral está facultado para otorgar medidas cautelares sin que la otra parte tengan conocimiento del pedido efectuado por el interesado.

55. Por último, el Contratista finaliza precisando que la tramitación de la solicitud del dictado de medida cautelar se ciña al criterio de confidencialidad y reserva, pues considera altamente probable que la Entidad, de tomar conocimiento, irregularmente, de la presente solicitud cautelar, ejecute las cartas fianza a su disposición, causándole así un perjuicio irreparable, eludiendo la efectividad del pronunciamiento del Tribunal Arbitral, y mermando o eliminando la eficacia de la decisión que se emitirá en este arbitraje.

## VI. ABSOLUCIÓN DE TRASLADO Y OPOSICIÓN DE LA ENTIDAD

56. Al respecto, es necesario manifestar que la Entidad no cumplió con pronunciarse respecto de la medida cautelar ni ofreció ningún medio de prueba. Pese a ser debidamente notificada por el Centro de Arbitraje.

## VII. ANÁLISIS Y POSICIÓN DEL ÁRBITRO DE EMERGENCIA

### a. Sobre los medios de prueba y su valoración

57. De modo previo al inicio de la redacción del análisis realizado en el presente procedimiento cautelar, el Árbitro considera pertinente precisar a las Partes que en la revisión, el estudio y el análisis correspondiente ha tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas por ambas, así como todos los medios probatorios aportados, realizando una valoración genérica y seria de los mismos –

tomando en cuenta la naturaleza del arbitraje de emergencia (tutela de urgencia, temporal, provisoria), que difiere de un arbitraje sobre el fondo en el que hay diversas estaciones procedimentales en las que se desarrollan actuaciones probatorias y se realiza una extensa dialéctica a lo largo de un tiempo suficiente para que las partes puedan ejercer sus derechos de modo amplio y pleno, y para que al Árbitro pueda alcanzar un nivel de certeza que le brinde la tranquilidad suficiente para emitir una decisión que ponga final definitivo a la controversia–, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no hayan sido tomados en cuenta para su decisión.

58. Asimismo, con base en el principio de comunidad de la prueba, los medios probatorios incorporados al presente proceso de emergencia son parte integral del mismo, muy al margen de si resultan favorecedores a la posición de la parte contraria a la que los incorporó.

**b. Sobre la medida cautelar**

59. La figura del Árbitro de Emergencia ha sido concebida con el objeto de que la parte que requiera una medida cautelar urgente y que no pueda esperar hasta la constitución del Tribunal Arbitral, pueda solicitar una medida cautelar antes de la constitución del Tribunal Arbitral a un profesional especializado sin tener que recurrir al Poder Judicial.

60. La figura del árbitro de emergencia cuenta con desarrollo internacional en el Reglamento de Arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje, así el artículo 29º establece:

> ***"Artículo 29º***
> ***Árbitro de emergencia***
> ***La parte que requiera medidas cautelares o provisionales urgentes que no puedan esperar hasta la constitución del tribunal arbitral ("Medidas de Emergencia"), podrá solicitar tales medidas según las Reglas de Árbitro de Emergencia*** *previstas en el Apéndice V. Tal solicitud será aceptada por la Corte solo si es recibida por la Secretaría antes de la entrega del expediente al tribunal arbitral de conformidad con el Artículo 16 e independientemente de si la parte que la hace ha presentado ya su Solicitud de Arbitraje. (...)"* (Énfasis agregado)

61. Al respecto, la doctrina peruana señala que muchas instituciones arbitrales a nivel mundial han ido introduciendo en sus reglamentos de arbitraje la figura del árbitro de emergencia como una solución a casos en los cuales una parte necesita una medida de protección antes del inicio del procedimiento arbitral[1].

62. Debido a la regulación internacional del Árbitro de Emergencia, diversos centros de arbitrajes peruanos han incorporado la figura del árbitro de emergencia en sus reglamentos arbitrales, tal es el caso del Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, donde se regula al árbitro de emergencia y en el artículo 63° se establece:

> ***"Artículo 63º.-***
> ***Medida Cautelar emitida por Árbitro de Emergencia***
> 1. ***Hasta antes de la constitución del Tribunal Arbitral, cualquiera de las partes que requiera medidas cautelares urgentes puede solicitar que se inicie un procedimiento ante un árbitro de emergencia, quien conoce y resuelve la respectiva solicitud.***
> 2. ***Las decisiones adoptadas por el Árbitro de Emergencia son vinculantes para las partes, quienes, por el hecho de haber sometido la controversia a arbitraje bajo el Reglamento, se obligan a cumplirlas sin demora.***
> 3. ***Se extingue la competencia del Árbitro de Emergencia por la constitución del Tribunal Arbitral.***
> 4. ***El derecho de las partes de recurrir a un Árbitro de Emergencia no impide que cualquiera de ellas pueda solicitar a la autoridad judicial competente que dicte medidas cautelares." (Énfasis agregado)***

63. Por lo que, el Árbitro de Emergencia es aquella persona que va a resolver una petición de medida cautelar de carácter urgente, la cual puede ser solicitada hasta antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo.

64. Para ello, se debe tener claro que las medidas cautelares son herramientas jurídicas -con que se puede contar desde antes del inicio del proceso- utilizadas por los tribunales (judiciales o arbitrales) durante la prosecución de un litigio o arbitraje, a través de las

---

[1] EZCURRA Huáscar y OLORTEGUI Julio; Litigio Arbitral: el arbitraje desde otra perspectiva; Editorial Palestra; Lima – 2016; p.p.195.

cuales se busca resguardar la pretensión en controversia mientras dure el procedimiento arbitral, con el propósito de garantizar su vigencia por el paso del tiempo facilitando el cumplimiento o la ejecución de la sentencia o el laudo final.[2] De allí que su función e importancia sea sustancial[3].

65. Asimismo, se debe considerar que el objeto de las medidas cautelares puede ser diverso, como conservar el *statu quo*, es decir, evitar la pérdida o el daño de algo, impedir el cambio de situación jurídica o física de bienes y derechos litigiosos, o bien prevenir la dificultad o imposibilidad de producción de ciertos medios probatorios, siempre por el paso del tiempo que el proceso inevitablemente tome. Por esta razón, lo que se busca es incitar que la conducta de las partes sea propicia para que un proceso judicial o el arbitraje sea exitoso y/o facilitar la ejecución ulterior de la sentencia y/o Laudo.

66. Por otro lado, para evaluar la procedencia de la pretensión cautelar solicitada, deben presentarse los siguientes requisitos en forma concurrente: (i) la *verosimilitud* del derecho invocado, (ii) la existencia de *peligro en la demora*, y (iii) la *adecuación* de la medida. Además, se debe otorgar una garantía suficiente o contracautela, que el titular de la medida cautelar debe ofrecer en resguardo de su pretensión.

67. En el presente caso, el Contratista formuló una solicitud de medida cautelar en relación con las controversias suscitadas entre este y la Entidad respecto a la resolución del Contrato, por lo que, para proveer de claridad expositiva, a continuación, se procede a citarla frente a la respuesta pertinente de su respectiva contraparte:

| PRETENSIÓN CAUTELAR FORMULADA POR EL CONTRATISTA | RESPUESTA DE LA ENTIDAD |
|---|---|

[2] GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Arbitraje, Editorial Porrúa, México, 2011, p. 625.

[3] "*(...) no solo tiene como finalidad asegurar el resultado del proceso, sino que, como señala REIMUNDÍN, tiende principalmente, mediante medidas adecuadas, a la conservación del orden y de la tranquilidad pública, impidiendo cualquier acto de violencia o que las partes quieran hacerse justicia por sí mismas durante la sustanciación del proceso, prescindiendo del órgano jurisdiccional*" (Cfr. LEDESMA NARVÁEZ, Marianella, Comentarios al Código Procesal Civil, Gaceta Jurídica, 2008, p. 6).

| | |
|---|---|
| • Solicitamos dicte medida cautelar consistente en ordenar a la Municipalidad Distrital de Santiago de Lucanamarca a que se abstenga a ejecutar:<br>(i) La Carta Fianza Nº 220301643-r5, emitida por INSUR S.A Compañía de Seguros, por el importe de s/. 397,563.94 (trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta y tres con 94/100 soles) que garantiza el fiel cumplimiento del Contrato Nº 097-2020-MDSL/GM. | • Entidad no cumplió con pronunciarse respecto de la medida cautelar ni ofreció ningún medio de prueba. Pese a ser debidamente notificada por el Centro de Arbitraje. |

**c. Con relación a la verosimilitud**

68. La verosimilitud del derecho invocado, esto es, el "*bonus fumus iuris*", consiste en la apariencia del derecho legítimo. La verosimilitud no supone que el Árbitro evalúe si las pretensiones que las partes vayan a formular sean fundadas o infundadas, sino que considere que, por lo menos, la pretensión tiene un sustento jurídico que la hace discutible. Por lo tanto, un derecho es verosímil cuando reviste apariencia de verdadero; la certeza del mismo se configurará recién cuando se adquiera convicción de su existencia, y tal extremo, de ser el caso, se expresa en la decisión final, esto es, en el Laudo.

69. Como explica Monroy Gálvez, "*advertido entonces que el peticionante de una medida cautelar únicamente necesita acreditar la apariencia de su derecho, resulta interesante describir cuál debe ser la conducta del juez ante tal petición. En nuestra opinión, al analizar la prueba en torno a la verosimilitud del derecho invocado, el juez debe realizar una estimación, diríamos mejor, un cálculo de probabilidades que le permita persuadirse que el derecho cuya cautela se pide, existe, en principio*"[4].

70. Asimismo, Kielmanovich señala que "*(...) las medidas cautelares no exigen un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo en grado de una aceptable verosimilitud, como la*

[4] MONROY GÁLVEZ, Juan, Temas de Proceso Civil, Studium, Lima, 1987, p. 26.

*probabilidad de que este exista y no como una incuestionable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite, si bien aquella debe resultar de los elementos incorporados al proceso que objetivamente y prima facie lo demuestren*"[5].

71. Entonces, en relación con este requisito, el Árbitro evaluará si el derecho invocado por el Contratista es o no verosímil, reiterándose que la verosimilitud no supone que el Árbitro analice y concluya sobre la invalidez e ineficacia de la resolución de contrato de parte de la Entidad, pues ello será objeto de evaluación profunda en el proceso arbitral principal, luego de transitar por todas las etapas pertinentes del proceso, incluyendo el debate de fondo correspondiente, para finalmente emitirse la decisión definitiva al momento de laudar.

72. El Árbitro tiene presente lo señalado por el Contratista: "*la medida cautelar de no innovar es la más adecuada, pues es precisamente la que tiene la naturaleza de conservar la situación de hecho y de derecho*". De ello se desprende que, en principio, la futura pretensión del Contratista sería la de solicitar se declare ineficaz e inválida la resolución del Contrato de la Entidad y la devolución de la carta fianza entregada a la Entidad.

73. Para ilustrar la controversia entre el Contratista y la Entidad, a continuación, se enumeran los siguientes hechos:

- El 30 de setiembre de 2020, las partes suscribieron el Contrato Nro. 097-2020-MDSL/GM, para la Ejecución de la Obra: "Creación de Pistas Veredas en los Jirones Jr. Compañía, Jr. 28 de Julio, Jr. Grau, Jr. Bolívar, Jr. 11 de junio, Jr. Brasil, Jr. Los Chankas y Jr. Porvenir en la Localidad de San José de Huarcaya del Distrito de Santiago de Lucanamarca – Huancasancos-Ayacucho".

- Dentro de los hechos que configuran particularmente la postura del Contratista, ya que la Entidad no cumplió con pronunciarse respecto de la medida cautelar ni ofreció ningún medio de prueba, Terrasoft Contratistas S.A.C., señala que, habría requerido a la Entidad el pago de las valorizaciones Nro. 01, 02 y 03 correspondientes al adicional de Obra Nro. 01 que ascienden al monto de S/. 422, 420.48 soles (cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos veinte con 18/100 soles).

---

5 KIELMANOVICH, Jorge L. Teoría del Proceso Cautelar. Medidas Cautelares. Editorial: Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002; p. 316.

- Según el Contratista, posterior al no cumplimiento del pago de las valorizaciones, y en atención a lo dispuesto en el artículo 164.2 del RLCE, se resolvió el Contrato mediante Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, notificada a la Entidad el 21 de diciembre de 2021.

- En este escenario, el solicitante manifestó que, de los hechos expuestos, la Entidad, al no controvertir la resolución del Contrato durante el plazo previsto en el artículo 166.3 del RLCE, cuya fecha límite para hacerlo era el 07 de febrero del 2022, esta resolución habría quedado consentida.

- Asimismo, el Contratista, preciso que la Entidad resolvió el Contrato con fecha 11 de febrero de 2022, mediante Carta Notarial S/N.

- Por último, se adjuntó como medio probatorio la Carta Notarial S/N enviada por la Entidad a INSUR – Partner of Atradius, con fecha 24 de mayo de 2022, solicitando la ejecución de la carta fianza N° 2020301643-R5 de fiel cumplimiento del contrato

74. En atención a ello, se observa que se ha generado un escenario de incertidumbre sobre la resolución del Contrato y la ejecución de la Carta Fianza de fiel cumplimiento.

75. A partir de ello, la controversia que será objeto del futuro arbitraje entre las partes tendría como eje que el Árbitro verifique y determine si la resolución del contrato realizado por la Entidad es ineficaz o inválida en mérito a la valoración de los medios probatorios que se presenten y actúen durante las actuaciones arbitrales.

**d. ¿De qué trata la solicitud de medida cautelar formulada por el Contratista?**

76. Su pretensión principal es: "(...) *ORDENAR A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA A QUE SE ABSTENGA A EJECUTAR: (i) La CARTA FIANZA Nº 220301643-R5, emitida por INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, por el importe de S/. 397,563.94 (Trescientos noventa y siete mil quinientos sesenta y tres con 94/100 soles) (...)*".

77. La petición cautelar del Contratista está directamente relacionada con el proceso arbitral que se iniciará contra la Entidad respecto de la ineficacia y/o invalidez de su resolución del Contrato y la solicitud de devolución de la carta fianza, por lo que resulta importante evaluar la concesión o no de una medida cautelar.

**e. ¿De qué trata el presente caso?**

78. El Árbitro considera necesario tener presente, en un primer momento, las siguientes Cláusulas del Contrato:

> **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**
> El presente contrato tiene por objeto **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LOS JIRONES JR COMPAÑÍA, JR 28 DE JULIO, JR GRAU, JR BOLIVAR, JR 11 DE JUNIO, JR BRASIL, JR LOS CHANKAS Y JR PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA-HUANCA SANCOS-AYACUCHO**

> **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO[1]**
> LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **SOLES**, en periodos de valorización **SERA MENSUAL**, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de **15** días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.
>
> En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

79. Sobre la base contractual antes descrita, se observa que el Contratista recibió el encargo de realizar la obra y la Entidad de pagar las valorizaciones.

80. Sin embargo, durante la ejecución del Contrato se habrían presentado incidentes que generaron discrepancias respecto del pago de las valorizaciones entre las Partes, las cuales dieron lugar a su resolución inicialmente por el Contratista; y, subsiguientemente, por la Entidad.

81. En esa línea, se tiene en el expediente arbitral la Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, de fecha 21 de diciembre de 2021, notificado en esa misma fecha, por la que el Contratista comunicó a la Entidad la

resolución del Contrato por las causales establecidas en el numeral 2) del artículo 164 de la RLCE, conforme al siguiente detalle:

> En tal situación, y al amparo de lo establecido en el artículo 164.2 del Reglamento del Texto Único Ordeno de la Ley de Contrataciones del Estado Nro. 30225 aprobado mediante D.S. Nro. 344-2018-EF, **COMUNICAMOS NUESTRA DECISION DE RESOLVER EN FORMA TOTAL EL CONTRATO** N° 97-2020-MDSL/GM para la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS VEREDES EN LOS JIRONES JR. CAMPAÑIA, JR. 28 DE JULIO, JR. GRAU, JR. BOLIVAR, JR. 11 DE JUNIO, JR. BRASIL, JR. LOS CHANKAS Y JR. PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEH HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANARMARCA – HUANCA SANCOS- AYACUCHO.

82. Subsiguientemente, se tiene en el expediente arbitral la Carta Notarial S/N, de fecha 11 de febrero de 2022, por la que la Entidad comunicó al Contratista la resolución del Contrato por la causal de resolución de Contrato establecida en la Cláusula Décima Sexta del Contrato, conforme al siguiente detalle:

> **4.** Asimismo, debemos remitirnos a la CLÁUSULA DECIMA SEXTA, que versa sobre la resolución del contrato: *"Cualquiera de las partes puede resolver el contrato de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, la entidad procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".*

> **6.** A la fecha, debemos señalar que su representada no ha cumplido con presentar a la entidad la valorización N.° 10 correspondiente al mes de diciembre de 2021, así como tampoco ha cumplido con justificar tal retraso, existiendo inclusive fecha prorrogada del plazo en la entrega de la valorización faltante y consecuente culminación de la ejecución de obra. Por lo que, a la fecha se encuentra inmersa en retraso injustificado. Por lo que, mediante la presente se comunica a su representada la RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N.° 097-2020-MDSL/GM, por incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de su representada.

83. En este orden de ideas, el Contratista, reforzó sus argumentos arguyendo que, si la Entidad no se encontraba conforme con la resolución de Contrato que su persona realizó el 21 de diciembre de 2021, debió recurrir a alguna de las vías de solución de controversias en un plazo de treinta (30) días hábiles, pero como dicha situación no se ha generado; por lo que, la resolución de Contrato efectuada por su el Contratista habría quedado consentida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 166.3 de la

RLCE. Por lo tanto, el Contratista agregó que se entiende que su resolución del Contrato ha quedado consentida, precisando que la fecha límite para controvertir la resolución del Contrato era el 07 de febrero del 2022.

84. Entonces, hay claridad respecto de que la discrepancia relevante entre las partes, que se ha traído al presente procedimiento de urgencia y que será discutida en el arbitraje a ser instaurado, gravitaría sobre lo siguiente: (i) La invalidez e ineficacia de la resolución del Contrato efectuada por la Entidad, y la devolución de la carta fianza.

**f. Sobre la resolución del Contrato realizado por el Contratista**

85. El presente Contrato regula la resolución de Contrato de acuerdo con lo señalado en su Cláusula Décima Sexta, como se puede observar a continuación:

> *"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado."*

86. Asimismo, sobre las causales y los efectos de resolución del Contrato, están previstas en los artículos 164 y 166 del RLCE, que establecen lo siguiente:

> *"Artículo 164. Causales de resolución*
> *(...)*
> *164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato."*
>
> *"Artículo 166. Efectos de la resolución*
> *166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.*

> *166.2. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.*
> *166.3. Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida*"

87. Como es de perfecto conocimiento de ambas Partes, aquí no se determinará la validez y eficacia de la mencionada resolución, pues ello corresponde al arbitraje sobre el fondo con las etapas pertinentes para que cada una pueda acreditar fehacientemente sus posiciones.

88. Ahora bien, para evaluar la existencia de la verosimilitud del derecho alegada por el Contratista en su petición cautelar, respecto a la devolución de la Carta Fianza, se observa que esta se basa en que, la Entidad debió recurrir a alguna de las vías de solución de controversias en un plazo de treinta (30) días hábiles, pero como según ha señalado el Contratista, dicha situación no se habría generado, la resolución de Contrato efectuada por su ella habría quedado consentida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 166.3 de la RLCE.

89. Al respecto, lo primero que merece ser destacado es que en la Carta Notarial N° 040-2021-TERRASOFT CONTRATISTAS SAC/GAM/RL, por la cual el Contratista resolvió el Contrato, fue emitida el 21 de diciembre del 2021 y notificada en la misma fecha; sin embargo, la Carta Notarial S/N, por la cual la Entidad resolvió el Contrato, fue emitida el 11 de febrero de 2022 y notificada en la misma fecha.

90. Sobre esta situación, en esta revisión cautelar (por ende, apriorística), hay una cosa que se torna especialmente relevante; que es analizar si la resolución de contrato efectuada por el Contratista si de un análisis aparente haya quedado consentida o no, y para ello es necesario revisar si la Entidad ha iniciado un arbitraje sobre esta resolución.

91. En atención a los hechos acontecidos en el marco del Contrato y los medios probatorios que obran en el expediente cautelar, el Árbitro Único analizó la documentación –de modo preliminar por la naturaleza del trámite cautelar de emergencia–, por la cual concluye que no se ha podido acreditar fehacientemente que la Entidad haya emitido

un pronunciamiento respecto a la resolución de Contrato realizada por el Contratista, ni tampoco se corroboró que lo haya derivado a arbitraje, precisando que la Entidad no cumplió con pronunciarse respecto de la medida cautelar ni ofreció ningún medio de prueba.

92. Como se puede observar el solicitante ha resuelto el contrato bajo la causal de incumplimientos por parte de la Entidad, la misma que se encuentra establecida en el numeral 2 del artículo 164 del RLCE, para esto, la Opinión Nº 027-2014/DTN de fecha 13 de febrero del 2014 emitida por la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante OSCE), que justamente analiza la Resolución de contrato por incumplimiento, concluyendo que:

> "*Un contratista puede resolverle a la Entidad un contrato por incumplimiento injustificado de sus obligaciones esenciales y, adicionalmente, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del mismo.*" (Énfasis nuestro)

93. Aunado a lo anterior, la Dirección Técnica Normativa del OSCE también ha emitido la Opinión Nº 190-2015/DTN de fecha 28 de diciembre del 2015, que analiza que el pago a cargo de la Entidad constituye una obligación esencial, precisando que:

> "*es importante indicar que el pago de la contraprestación constituye la principal obligación esencial que toda Entidad debe cumplir para satisfacer el interés económico del contratista, pudiendo existir otro tipo de obligaciones esenciales en función a la naturaleza u objeto del contrato o a las prestaciones involucradas.* (Énfasis nuestro)

94. Asimismo, la Opinión Nº 046-2020/DTN de fecha 24 de junio del 2020 emitida por la Dirección Técnica Normativa del OSCE, manifiesta el plazo para que las partes puedan cuestionar la resolución de contrato, precisando:

> "*En adición a lo señalado, cabe agregar que cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede* ***ser sometida a los medios de solución que contemplan la Ley y el Reglamento, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada dicha resolución***." (Énfasis nuestro)

95. En ese sentido, conforme al artículo 166 del RLCE, para que una resolución no quede consentida, es necesario advertir que la contraparte active los procedimientos de

solución de controversias, solicitando la conciliación o el arbitraje y tampoco se aprecia en los medios probatorios aportados que la Entidad haya cuestionado el procedimiento y el efecto de la causal de resolución contractual invocada por el Contratista.

96. El consentimiento por la inacción dentro del plazo de los treinta (30) días hábiles respecto a la parte que desea cuestionar la resolución de contrato, es sumamente importante, pues de acuerdo con el artículo 45 de la LCE, este plazo se entiende que es de caducidad, precisando que la misma trae corno consecuencia la extinción del derecho material y la acción correspondiente, situación que no le permitirá al contratista o a la Entidad, según el caso, cuestionar la resolución del contrato debido a que esta ha quedado consentida.

97. En ese sentido, dado que la decisión del Contratista de resolver el contrato parece no haber sido cuestionada por la Entidad, a través de los mecanismos de solución de controversias su decisión de resolver el contrato, dentro del plazo de ley, parece haber quedado consentida; por lo que, con base en este análisis no se podría desconocer los efectos de dicha situación general, la cual en el arbitraje principal ya deberían de hacer un análisis profundo de los hechos que podrían ser imputables a la Entidad.

98. Además, el Árbitro considera necesario transcribir lo señalado en el artículo 136 del RLCE, que establece el procedimiento y los efectos por resolver el Contrato:

> *Artículo 136.- Procedimiento de resolución de Contrato*
> *Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*
> *Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.*
> *Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.* ***El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación****.*" (Énfasis nuestro)

99. En ese sentido, es necesario mencionar la Opinión N.º 086-2018/DTN de fecha 19 de junio del 2018, emitida por la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, al comentar el precitado artículo manifiesta que:

> *"2.2.1. (...) Como puede evidenciarse, la resolución contractual se materializa una vez que la parte requerida* ***recibe la comunicación donde su contraparte (la parte afectada) le informa la decisión de resolver el mismo;*** *por tanto,* ***desde aquel momento, el contrato dejará de surtir efectos y ambas partes -Entidad y contratista-*** *quedarán desvinculadas.*
> *(...)*
> *Es importante reiterar que la debida* ***resolución del contrato produce sus efectos una vez que la parte requerida recibe la comunicación donde su contraparte*** *(la parte afectada) le informa la decisión de resolver el mismo, para lo cual previamente debe haberse seguido el procedimiento previsto en el artículo 136 del Reglamento"* (Énfasis nuestro)

100. Entonces, conforme lo señala el OSCE, el Árbitro manifiesta que una vez puesta a conocimiento la resolución de Contrato, ésta surte sus efectos frente a las partes. Sobre este punto, es preciso citar al doctor De La Puente Y Lavalle[6], como doctrina autorizada, quien menciona lo siguiente:

> *"(...) la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal manera que ella* ***deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones."*** (El subrayado es agregado).

101. Por lo que, para determinar el efecto jurídico en relación con la Carta Notarial S/N de fecha 11 de febrero de 2022, mediante el cual la Entidad resolvió el Contrato, siendo la misma posterior a la resolución practicada por el Contratista, nos remitimos a lo señalado por el OSCE en la Opinión N.º 086-2018/DTN, precisando lo siguiente:

> *"(...)* ***sí una de las partes (Entidad o contratista) resuelve debidamente un contrato*** *–es decir, siguiendo el procedimiento y cumpliendo los requisitos y formalidades previstas en la normativa de contrataciones del Estado-* ***no cabría la posibilidad de que su***

[6] DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contrato en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo I, Lima: Palestra Editores S.R.L., 2001, pág. 455

> ***contraparte efectué una nueva resolución respecto del mismo contrato, puesto que, para entonces, la relación jurídica ya se encontraría extinta."*** *(Énfasis nuestro)*

102. Asimismo, mediante el artículo 155 del RLCE, se precisa en qué supuestos la Entidad puede ejecutar las garantías presentadas por el Contratista:

> *"155.1 Las garantías se ejecutan en los siguientes supuestos:*
> *a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con la conformidad de la recepción de la prestación o haya quedado consentida la liquidación, según corresponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos, no corresponde devolución alguna por el adelanto pendiente de amortización.*
> *b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.*
> *c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o en la liquidación final del contrato, en el caso de consultoría de obras y ejecución de obras. Esta ejecución es solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.*
> *d) La garantía por adelantos se ejecuta cuando resuelto o declarado nulo el contrato, no se realice la amortización o el pago, aun cuando este evento haya sido sometido a un medio de solución de controversias."* (Énfasis nuestro)

103. Sobre ello, de un análisis de la norma, se puede entender que es necesario que la Entidad haya resuelto el contrato por culpa atribuible al Contratista y que haya quedado consentida, situación que conforme a los hechos señalados no se ha

demostrado y es más, es justamente un pedido como pretensión en el arbitraje principal el cuestionamiento de la resolución de contrato por parte de la Entidad.

104. Al respecto, se precisa que conforme lo analizado por los artículos 136 y 155 del RLCE y lo establecido por el OSCE mediante sus opiniones, se reafirma su posición sobre las consecuencias jurídicas de una resolución de Contrato y las causas por las cuales se puede ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por parte de la Entidad.

105. Por estas razones, sobre la base de una primera aproximación –propia del trámite de un arbitraje de emergencia–, en virtud de los medios probatorios ofrecidos en el arbitraje, el Árbitro concluye que hay elementos de convicción suficientes para considerar que la resolución del Contrato formulada por el Contratista habría quedado probablemente consentida, por lo que se presenta cierta verosimilitud en el derecho invocado por el Contratista; por lo que sobre ello, no sería viable la ejecución por parte de la Entidad de la carta fianza de fiel cumplimiento.

106. No obstante, dicha situación será dilucidada en el proceso principal y analizada y decidida en el respectivo Laudo Arbitral, para la concesión de la presente petición cautelar, el Árbitro no tiene duda de que estas se encuentran directamente vinculadas a la decisión final que emanarán del arbitraje principal.

107. Esto debido a que en el presente procedimiento cautelar se discute la posibilidad de que la Entidad ejecute la carta fianza por la Garantía de Fiel Cumplimiento emitida a su favor en el marco de la ejecución del Contrato y, al tratarse la controversia de fondo sobre la ineficacia o invalidez de la resolución del contrato por parte de la Entidad y la devolución de la precitada carta fianza, como lo ha expresado el Contratista en la solicitud de medida cautelar y medios probatorios ofrecidos, en el Laudo Arbitral sobre dicha controversia se determinará (al menos indirectamente) si la Entidad se encontraba legítimamente habilitado para ejercer el derecho potestativo de ejecutar la carta fianza otorgadas por el Contratista en su favor, para lo cual, entre otros, se verificará si el mismo incumplió o no sus obligaciones esenciales.

108. Asimismo, el Árbitro considera necesario indicar que el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por el Contratista no importa la restricción de los derechos legítimos de la Entidad; por el contrario, lo que se busca es mantener el statu quo de los derechos que ambas partes discutirán en el proceso arbitral. Es así como si, por un lado, el resultado del proceso principal resulta favorable al Contratista, no se habrá ejecutado de manera innecesaria o irregular la carta fianza por la Garantía de Fiel Cumplimiento, pero si, por otro lado, la controversia de fondo resultase favorable para

la Entidad, su derecho de poder ejecutar dicha garantía se mantendrá y, asimismo, encontrará resarcido mediante la contracautela que se determine en la presente Resolución.

109. De este modo, debe quedar claro que, si se ejecutase la carta fianza antes de la emisión del eventual Laudo Arbitral, y el resultado de dicha decisión fuese favorable al Contratista, la ejecución prematura de las referidas garantías perjudicaría los efectos inmediatos que debería tener el Laudo Arbitral en caso este deje sin efecto la resolución del Contrato por parte de la Entidad. Por ello, para mantener incólume la situación en la cual se encontrará el proceso principal del futuro arbitraje y, siendo que las peticiones cautelares están directamente vinculadas al fondo de la controversia, corresponde otorgar la presente medida cautelar.

110. En consecuencia, para el Árbitro, el Contratista esgrime razones que permiten evidenciar una mínima verosimilitud en su solicitud de que se ordene a la Entidad que se abstenga de ejecutar o realizar cualquier acto orientado al cobro de la carta fianza de fiel cumplimiento (Nº 220301643-R5), emitida en su favor por INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, así como sus respectivas renovaciones que se hayan emitido y se emitan en el marco del Contrato, en tanto se resuelva en forma definitiva la controversia mediante un Laudo Arbitral en el que el Árbitro resuelva la controversia de fondo suscitada entre el Contratista y la Entidad.

111. Es así que, el Árbitro de Emergencia considera que la dación de una medida cautelar es necesaria para asegurar la eventual eficacia del posterior Laudo Arbitral.

**g. En relación con el peligro en la demora**

112. El peligro en la demora puede definirse como la constatación que hace el juzgador que, de no dictar o amparar la medida cautelar solicitada, una eventual decisión a la parte que solicita la medida resulte ilusoria o inejecutable.

113. En esa línea, la doctrina nacional[7] se ha pronunciado señalando que:

> *"El presupuesto de peligro en la demora se encuentra vinculado a la posibilidad razonable de que lo solicitado en la pretensión sufra un perjuicio, irreparable o no, en el transcurso del proceso, es decir, que exista el peligro objetivo de ocurrencia de un evento –que puede ser natural o voluntario- que haga imposible*

[7] JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, Roxana. Apuntes sobre Medidas Cautelares. Consultado en: http://www.justiciayderecho.org.pe/revista6/articulos/Apuntes%20s...pdf

> *o limite la realización de los intereses cuya satisfacción se ha solicitado vía pretensión*".

114. Ahora bien, el Árbitro Único tiene en consideración que, como cualquier otra petición, el peligro en la demora debe ser acreditado con actos o hechos concretos, que permitan formar convicción de que existe el presupuesto, y por lo tanto, se tiene por satisfecho. Como resulta evidente, además de ello, el Árbitro de Emergencia se encuentra limitado a analizar únicamente los hechos u otros bajo los cuales el Contratista ha sustentado el pedido cautelar.

115. A efectos de analizar este presupuesto, el Árbitro Único se remite a los caracteres que, de acuerdo con lo indicado por el profesor Priori Posada[8] configuran el peligro en la demora:

> "*a) El riesgo de daño jurídico debe ser causado por la demora del proceso; y,*
> *b) El riesgo de daño jurídico deber ser inminente, lo que justifica la necesidad de dictar una medida cautelar, que tiene el carácter de urgencia*".

116. Por lo tanto, con relación al requisito del peligro en la demora, consiste en el inminente perjuicio irreparable, el Árbitro tiene en consideración lo manifestado por el Contratista, referido a que, la Entidad ha solicitado a INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS la ejecución de la Carta Fianza N° 220301643-R5, y ello lo ha probado mediante Carta Notarial S/N [Anexo n del escrito de Solicitud Cautelar] enviado por la Entidad a INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS con fecha 24 de mayo del 2022, en el cual manifiesta expresamente que la Entidad ha solicitado la ejecución de la referida carta fianza.

117. Sobre lo expuesto, el Árbitro considera que, de no ordenarse a la Entidad que se abstenga de ejecutar la carta fianza emitida a su favor, los efectos del posterior Laudo Arbitral podrían verse perjudicados en caso la decisión contenida en dicho laudo fuese favorable del Contratista, así como el perjuicio económico inmediato que sufriría tal empresa si se ejecutara la referida garantía antes de que el Árbitro emita su decisión final sobre las pretensiones en el procedimiento arbitral.

118. En efecto, de suponer, desde ahora, que el Contrato ha sido válidamente resuelto por el Contratista, la ejecución de la carta fianza podría destruir la paridad en la situación jurídica de ambas partes en el eventual arbitraje, y ocasionar un daño que podría ser irreparable –el extremo de la irreparabilidad, que supone una precaria situación

---

8 PRIORI POSADA, Giovanni. "La Tutela Cautelar". Ara: Lima, 2006. Pág. 39.

económica del solicitante, es desconocido por el Árbitro- o, al menos, no de forma oportuna.

119. Así, en tanto el Contratista y la Entidad diluciden su controversia de fondo en un arbitraje, es necesario que la Entidad mantenga el statu quo o se abstenga de llevar a cabo actos relacionados con la ejecución de la carta fianza a la que se refiere la pretensión cautelar formulada por el Contratista, y que podría menoscabar la eficacia del eventual Laudo Arbitral, más aún si la controversia entre las partes radicaría en que el Árbitro determine si la resolución del Contrato por parte de la Entidad es inválida o ineficaz.

120. Por lo tanto, teniendo en consideración que toda medida cautelar está orientada a impedir algún daño o perjuicio entre las partes mientras se dirima la controversia de fondo, el Árbitro concluye que en el presente caso se verifica en la petición cautelar la concurrencia del peligro en la demora.

**h. En relación con la adecuación de la medida**

121. Respecto a la adecuación, de la medida cautelar, tiene por objeto identificar la idoneidad del pedido cautelar con los efectos que se eviten generar como consecuencia de la medida cautelar, es decir, implica que ha de existir correspondencia entre el contenido y los efectos de la cautela que se pide con la pretensión ejercida en el proceso principal.

122. La adecuación consiste en que las medidas cautelares sean congruentes con lo que se pide en la demanda y cuya eficacia se pretende garantizar y que sean proporcionales, es decir, lo menos gravoso posible para el que las soporta. La razonabilidad de la medida cautelar está referida a que la medida cautelar sea apropiada para el fin de garantizar la efectividad de la tutela del derecho discutido en el proceso principal

123. En ese sentido, el Árbitro considera necesario dejar claro que la presente solicitud cautelar no perjudica los derechos de la Entidad, ni tampoco se trata de una medida cautelar innovativa o desproporcionada que implique una obligación adicional a las asumidas por la Entidad en el Contrato, dado que simplemente se busca mantener indemne la situación en la que se encuentran la carta fianza.

124. Para ello, también es necesario contemplar que, con la concesión de una medida cautelar de la naturaleza formulada por el Contratista, esta última no solo obtendría una decisión cautelar provisoria a su favor, sino que también asumiría los costos

financieros de mantener vigente la carta fianza para el otorgamiento de una solicitud cautelar como la planteada en el presente caso.

125. Por esta razón, el Contratista tendrá que asumir todas las cargas necesarias que impliquen mantener incólumes la carta fianza que garanticen los derechos que eventualmente pueda reconocer un Árbitro a favor de la Entidad, y de emitir un Laudo Arbitral a favor de esta, la Entidad podrá ver resarcido el posible daño que sufra con la ejecución de la medida cautelar, a través de la contracautela que se determine en la presente Resolución.

126. Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, el Árbitro considera que corresponde declarar FUNDADA la pretensión principal de la solicitud cautelar formulada por el Contratista; en consecuencia, corresponde:

127. Ordenar a la Entidad que se abstenga de ejecutar o realizar cualquier acto orientado al cobro de la carta fianza de fiel cumplimiento (N° 220301643-R5), emitida en su favor por INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, así como sus respectivas renovaciones y/o prórrogas que se hayan emitido y se emitan en el marco del Contrato, en tanto se emita un Laudo definitivo en el que un Tribunal Arbitral resuelva la controversia de fondo suscitada entre el Contratista y la Entidad.

**i. Con relación a la Contracautela**

128. Respecto a la contracautela, que tiene por objeto asegurar a la Entidad el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera producirle la ejecución de una medida cautelar.

129. Sin perjuicio de ello, el Árbitro de Emergencia tiene en consideración que la contracautela consiste en una caución que presta el solicitante de la medida cautelar para garantizar el resarcimiento de cualquier perjuicio ilícito que pudiera sufrir el afectado de la medida cautelar como consecuencia de su ejecución.

130. El Árbitro de Emergencia ha analizado la presente Resolución la concurrencia de: (i) la verosimilitud del derecho invocado, (ii) la existencia de peligro en la demora y (iii) la adecuación de la medida cautelar, se analizan para determinar si corresponde otorgar o no una medida cautelar, es decir, su procedencia. Mientras que la contracautela se analiza para determinar si una medida cautelar debe ser ejecutada.

131. En la misma línea, el doctor Peyrano[9] señala que la prestación de la contracautela no es un requisito para su procedencia, sino solo un presupuesto para que resulte viable su ejecución.

132. En ese sentido, a la contracautela, que tiene por objeto asegurar al afectado el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera producirle la ejecución de una medida cautelar, el Árbitro tiene en consideración lo manifestado expresamente por el Contratista respecto a que ofrece como contracautela una de caución juratoria, para garantizar los daños que eventualmente origine el pedido cautelar, por el monto de S/. 20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles).

133. Sobre el particular, teniendo en cuenta que eventualmente se discutiría en un arbitraje el consentimiento de la resolución del Contrato ejercitada por la Entidad, y la devolución de la carta fianza, aspectos que aún no se han determinado, el Árbitro estima que es razonable y suficiente ordenar al Contratista ofrecer una caución juratoria con el objeto de asegurar los posibles daños y perjuicios que pudieran causarse a la Entidad con la ejecución de la medida cautelar.

134. Esto debido a que, mediante la presente resolución, no se está desconociendo la obligación del Contratista de renovar la carta fianza hasta que se dirima la controversia sobre la resolución del Contrato, sino que, por el contrario, se busca preservar los derechos de la Entidad que se garantizan con dicha carta fianza, conminando al Contratista a que, además, de ofrecer la caución juratoria requerida, asegure la vigencia de la carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento. Aspectos sobre los cuales las partes no han llegado a un acuerdo, y que tendrá que ser dilucidado en el arbitraje principal, con base en ello, hay razones suficientes para impedir que la Entidad ejecute la carta fianza, y de igual manera que mantenga la vigencia de dichas garantías.

135. Por lo tanto, la vigencia de la ejecución de la medida cautelar otorgada a favor del Contratista está condicionada a que dicha parte ofrezca dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada con la presente resolución cautelar, una caución juratoria.

136. Sobre la cuantía de la contracautela, el Árbitro considera lo siguiente: si al Contratista le fuera adversa la decisión final a ser emitida en el eventual Laudo Arbitral, ello significa que el Contrato estuvo resuelto por la Entidad, por lo que dicha parte habría tenido derecho de ejecutar la carta fianza de Garantía de Fiel Cumplimiento. Empero,

---

9 PEYRANO, Jorge. "Derecho Procesal Civil". Ediciones Jurídicas, Lima, Perú, 1995

se desconoce la cuantía exacta de los daños y perjuicios que pueda sufrir la Entidad en caso el resultado del proceso arbitral terminará siendo adverso al Contratista.

137. Por otro lado, esta medida cautelar es particularmente especial, dada la naturaleza de la medida de no innovar que se explica: la carta fianza es una garantía (sustantiva) emitida por el Contratista en favor de la Entidad; si la primera no cumple con sus obligaciones, la Entidad puede ejecutarla.

138. La medida cautelar en sí misma es una garantía (procesal): la garantía de que no se ejecutará la garantía antes de decidir si corresponde hacerlo o no. Y la contracautela es a su vez una garantía de la garantía: si la garantía que es la medida cautelar no debió otorgarse (si se declara infundada o improcedente la demanda), entonces con esta garantía (contracautela) se salvaguardan los daños y perjuicios que la concesión de la cautelar podría haber ocasionado. Por ende, en este caso la garantía (procesal) de que no se ejecute la garantía (sustantiva) debe contar con una contragarantía (procesal).

139. Dicho de modo sintético, si se desestimase la demanda, la garantía sustantiva (carta fianza) se ejecutaría de inmediato por la Entidad, la que nunca pierde su garantía; lo que le puede perjudicar es el momento en que la ejecutaría, esto es, la demora en contar con el monto dinerario. Pero si esta carta fianza se ejecutará desde ya (esto es, de no concederse la medida cautelar), el Contratista no tendría garantía alguna para recuperar el monto dinerario, debiendo ejecutar a la Entidad mediante proceso de ejecución (de laudo arbitral). De ahí que es relevante comprender lo que contienen de suyo las garantías jurisdiccionales en que consistente la medida cautelar y la contracautela, y la función que cumplen en el ordenamiento jurídico peruano, y también el contenido de lo que en el caso concreto se busca preservar (en este caso, la carta fianza, que son a su vez garantías).

140. En consecuencia, siendo un asunto sujeto a la decisión final del eventual Laudo Arbitral, y careciendo de la información necesaria para establecer monto alguno (esto es, no solo los intereses moratorios, sino el eventual daño ulterior -en caso se genere y fuese exigible de acuerdo con derecho-), el Árbitro señala que la cuantía de la caución juratoria será establecida, de ser el caso, en función de los daños que oportunamente se establezcan, por lo que se concede en forma ilimitada.

**j. Sobre la contracautela prevista en el Decreto de Urgencia 020-2020: "Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.**

141. Sobre el particular, el Árbitro, de oficio, tiene en consideración que el referido Decreto de Urgencia modificó determinados artículos del Decreto Legislativo 1071 – Ley de Arbitraje, entre los cuales está el artículo 8 de la referida ley, en el cual se incorporó el siguiente párrafo:

> ***"Artículo 8.- Competencia en la colaboración y control judicial.***
> *2. (...)*
> *En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y/o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada, por el tiempo que dure el proceso arbitral. El monto de la contracautela lo establece el/la juez/a o el tribunal arbitral ante quien se solicita la medida cautelar, dicho monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento. La ejecución de la carta fianza se establece conforme a lo resuelto por el/la juez/a o el tribunal arbitral, según corresponda."*

142. El Árbitro consideró necesario dejar claro que de exigir al Contratista una contracautela como la establecida por el referido decreto de urgencia sería eminentemente desproporcional para dicho Contratista, dado que el monto de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, razón por la cual una contracautela que consista en una carta fianza por el mismo monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato provocaría que el Contratista vea restringido su derecho a la tutela cautelar y/o tutela de urgencia, que forman parte del derecho constitucional a la tutela jurisdiccional.

143. En efecto, exigirle al Contratista una o más garantías por el mismo monto de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento sustraería de contenido a la medida cautelar establecida en la presente resolución, dado que con esta se pretende cautelar el *statu quo* de ambas partes y, concretamente, la situación patrimonial del Contratista, mientras no se determine en un Laudo Arbitral la validez y legitimidad de la resolución del Contrato formulada por la Entidad. Además, si lo que se pretende evitar es que el solicitante vea perjudicada su situación financiera por una incorrecta ejecución de la carta fianza, no resulta lógico ni proporcional que se le exija –como requisito para amparar su pretensión cautelar– una contracautela por el mismo monto de la carta fianza cuyo mandato de inejecución ha solicitado al Árbitro.

144. Asimismo, el Árbitro tiene presente que tal regla vulnera el principio/derecho constitucional de igualdad, que forma parte de la tutela cautelar efectiva en todo el

procedimiento jurisdiccional, incluido el arbitraje, colisionando además con otro de los presupuestos cautelares, como es el de la razonabilidad[10].

145. Los procesos judiciales y los arbitrales gozan de iguales garantías constitucionales, estando ambos inmersos en el concepto de jurisdicción, que los protege y salvaguarda. Así las cosas, los procesos judiciales son tramitados en su mayoría bajo las normas del código procesal civil (siendo que los cuerpos normativos procesales especiales contienen normas similares), que establece parámetros para la concesión de las medidas cautelares, así como para la exigencia de la contracautela, la que tiene como objeto y finalidad garantizar los daños que eventualmente pudiese ocasionar la medida cautelar (es la garantía de la garantía). Y en cada caso, por esa razón, debe evaluarse la verosimilitud (a mayor verosimilitud, menor contracautela), el peligro en la demora y el posible daño que pudiera causar la medida: con base en todo ello se calibrará la cuantía y el tipo de contracautela.

146. De ese modo, rompe toda la teoría cautelar universal el exigir, de modo indiscriminado, para cualquier pedido cautelar que solicite el Demandado contratista en un arbitraje contra el Estado, una carta fianza que tenga mínimamente el valor de toda la garantía de fiel cumplimiento. Ya no se trata de una contracautela, sino en buena cuenta de una inconstitucional barrera de acceso a la tutela de urgencia que solo busca que el proceso discurra sin el temor de que el laudo arbitral carezca de eficacia real. Se trata también, como se dijo, de una afectación al derecho a la igualdad (igualdad del contratista frente al Estado a quien no se le exige semejante requisito; igualdad de los arbitrajes en los que el Estado es parte frente a los demás arbitrajes; igualdad del arbitraje frente a los procesos judiciales, etc.).

147. En ese sentido, el Árbitro considera que la norma contenida en el DU 020-2020, tal como se ha plasmado en la ley de arbitraje general (Decreto Legislativo 1071), aparentemente se encuentra incompleta, le falta desarrollo, por lo que no resulta, de ser el caso, aplicable. Y, de considerarse que se encuentra completa, entonces por su falta de razonabilidad, proporcionalidad y su incompatibilidad con los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Política del Perú, el Árbitro de Emergencia concluye que no es factible que pueda ser aplicada al presente caso, por cuanto el solicitante ha pedido poder tramitar esta controversia sin el golpe financiero que le resultaría la ejecución de la carta fianza, alegando, entre otros motivos, dificultades de

[10] MATHEUS, Carlos. Comentarios al Decreto de Urgencia sobre la Ley de Arbitraje peruana. En: ciarglobal.com, Lima, 3 de febrero de 2020.

financiamiento, por lo que obtener una carta fianza nueva y adicional por la misma cuantía le resultaría, en su caso concreto, una limitación en extremo severa.

148. Así, el Árbitro de Emergencia concluye que, más allá de que en general la norma contenida en el DU 020-2020 parece encontrarse inacabada, o que si estuviese acabada parece ser inconstitucional (porque no discrimina entre los distintos casos, pedidos cautelares, etc.) -salvo para casos en los que la cuantía y entidad de la contracautela establecida en la norma coincida con la que debería ser aplicada en tales supuestos-, y es que, en este caso en concreto sí se vulnera los principios y derechos constitucionales y genera un estado de indefensión en el solicitante al vulnerar sus derechos a la igualdad, al acceso a la tutela jurisdiccional de urgencia y al debido proceso. En tal sentido y por las razones explicadas, él considera su deber el aplicar el control difuso.

149. Al respecto, en el ordenamiento jurídico peruano no se encuentra en cuestión la posibilidad de los tribunales arbitrales de hacer uso del control difuso de la constitucionalidad de las leyes, poder-deber que el artículo 138 de la Constitución atribuye a los jueces para no aplicar al caso concreto la norma legal que resulte incompatible con la Constitución, puesto que la misma es una herramienta constitucional -propia de la concepción del Estado Constitucional de Derecho- conferida a los órganos y tribunales dotados de jurisdicción (teniendo como fundamento los principios de independencia y unidad de la función jurisdiccional), en la medida que la norma que se inaplique sea absolutamente pertinente y relevante para la eficacia de la decisión a tomar, y que suponga un perjuicio al derecho de una de las Partes[11].

150. Así lo ha señalado de forma expresa y vinculante el Tribunal Constitucional en la STC 142-2011-PA/TC:

> *"22. Líneas arriba hemos recordado que, conforme al artículo 139° inciso 1) de la Constitución, el arbitraje es una jurisdicción independiente del Poder Judicial o jurisdicción común, que se explica no como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, ni tampoco como su sustituto, sino como una alternativa que complementa el sistema judicial, puesta a disposición de la sociedad para la solución pacífica de las controversias, básicamente de orden patrimonial de libre disposición.*

[11] Precedente Vinculante: STC 142-2011-PA/TC - Sociedad Minera de Responsabilidad Ltda. Maria Julia

*23. Esto no afecta el principio de unidad de la función jurisdiccional (que implica que el Estado, en conjunto, posea un sistema jurisdiccional unitario, en el que sus órganos tengan idénticas garantías, así como reglas básicas de organización y funcionamiento), ya que, como ha señalado este Tribunal, «de ello no se deduce que el Poder Judicial sea el único encargado de la función jurisdiccional (pues tal función se le ha encargado también al Tribunal Constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones, a la jurisdicción especializada en lo militar y, por extensión, al arbitraje), sino que no exista ningún órgano jurisdiccional que no posea las garantías propias de todo órgano jurisdiccional. Como se ha mencionado, la función jurisdiccional del Estado es una sola y debe ser ejercida con todas las garantías procesales establecidas por la Constitución (STC 0004-2006-PIITC, fundamento 10).*

*Siendo el arbitraje una jurisdicción independiente, como expresamente señala la Constitución, y debiendo toda jurisdicción poseer las garantías de todo órgano jurisdiccional (como las del Poder Judicial), es consecuencia necesaria de ello que la garantía del control difuso de constitucionalidad, prevista en el segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución, pueda también ser ejercida por los árbitros en la jurisdicción arbitral, pues el artículo 138° no puede ser objeto de una interpretación constitucional restrictiva y literal, como exclusiva de la jurisdicción ordinaria o constitucional.*"

151. Entonces, siendo el arbitraje un método de solución de controversias con reconocimiento jurisdiccional por la Constitución Política del Perú, y, además, teniendo el árbitro el deber de ejercer el deber jurisdiccional de resolver un determinado conflicto, el Árbitro de Emergencia tiene la obligación de emitir decisiones que respeten el orden jurídico sustantivo y procesal, que esté íntimamente ligado a los postulados fundamentales de la Constitución y aquellas normas legales

152. Considerando lo anterior, y en síntesis, no cabe duda de que la determinación de la contracautela debe guardar coherencia con el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad en relación con la medida cautelar solicitada. Además, el principio de igualdad[12] es un pilar constitucional que exige la paridad de trato en toda

[12] Sobre dicho principio, el Tribunal Constitucional ha establecido que la igualdad es un principio derecho que instala a las personas, situadas en idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluya a una persona de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones (STC 0018-2003-AI/TC).

relación o situación jurídica, y con mucha más razón en un proceso arbitral como el del presente caso, donde se debe respetar escrupulosamente el debido proceso, el cual implica que ambas partes gocen de las mismas condiciones para defender sus derechos, y en el que se ha observado, en forma específica, que de exigirse la contracautela a que hace referencia el DU 020-2020 se configuraría un desbalance de gran magnitud y desproporción, generándose una inconstitucional barrera de acceso a la tutela de urgencia.

153. En razón de todo lo expuesto, el Árbitro de Emergencia concluye que no correspondería exigir al solicitante el ofrecimiento de una Carta Fianza por el mismo monto de la garantía de fiel cumplimiento emitido por el solicitante a favor de la Entidad como una contracautela, debido a que hacerlo, se estarían vulnerando los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad e igualdad que integran el derecho a la tutela jurisdiccional.

154. Sin perjuicio de lo anterior, el Árbitro de Emergencia considera que con el fin de asegurar que la Entidad no sufra algún tipo de daño y/o perjuicios con la ejecución de la medida cautelar a favor del solicitante, resulta pertinente y necesario que el solicitante cumpla con ofrecer una contracautela en modalidad de caución juratoria de cuantía ilimitada, ya que la misma es un requisito indispensable para asegurar la vigencia de la medida cautelar otorgada a favor del solicitante y que consta en la presente resolución.

## VIII. DECISIÓN

1. El Árbitro de Emergencia considera pertinente señalar que el Contratista ha esgrimido razones que permiten al Árbitro de Emergencia -sin emitir pronunciamiento de certeza ni definitivo sobre el fondo del presente arbitraje, sino tan solo un pronunciamiento provisional con base en la revisión de los documentos aportados- evidenciar una *mínima verosimilitud* del derecho invocado, lo que ha llevado a concluir que la dación de la medida cautelar es necesaria para asegurar la eficacia del posterior Laudo Arbitral.

2. Asimismo, el Árbitro de Emergencia considera pertinente enfatizar que la concesión de una medida cautelar no vinculará al análisis que efectúe el Tribunal Arbitral que conozca la presente controversia, pues no constituye un pronunciamiento definitivo respecto del fondo de la controversia, siendo que al momento de laudar el Tribunal Arbitral respectivo puede -habiendo analizado a profundidad los medios de prueba aportados y actuados en las etapas correspondientes, así como oído las alegaciones de las partes- decidir en sentido distinto, opuesto o diverso al de la medida cautelar

solicitada al conocer y analizar los alcances y circunstancias del objeto controvertido y las posiciones de las Partes[13].

3. Finalmente, cabe señalar que el sentido de la presente Resolución es el resultado del análisis sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en la presente decisión.

4. Por las consideraciones que preceden, el Árbitro de Emergencia emite la presente Resolución, declarando:

**PRIMERO**: Declarar **FUNDADA** la pretensión principal de la solicitud cautelar formulada por TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C., mediante su escrito del 25 de mayo de 2022; en consecuencia:

**SE DISPONE** ordenar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA que se abstenga de ejecutar o realizar cualquier acto orientado al cobro de la carta fianza de fiel cumplimiento (N.º 220301643-R5), emitida en su favor por INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, así como sus respectivas renovaciones y/o prórrogas que se hayan emitido y se emitan en el marco del Contrato, en tanto se emita un Laudo definitivo en el que un Tribunal Arbitral resuelva la controversia de fondo suscitada entre el Contratista y la Entidad.

**SEGUNDO: SE DISPONE A COMUNICAR** a INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con el contenido de la presente decisión cautelar, emitida por un Árbitro de Emergencia en el marco del Reglamento del Centro, que cuenta con función jurisdiccional, a fin de que se abstenga de tramitar la solicitud de ejecución o de cualquier otro acto de lo

[13] En ese sentido, la Corte Suprema señala que "[la medida cautelar no impone un estado jurídico inatacable]; por el contrario, más allá de la probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor del proceso, lo cierto es que toda cautelar es provisoria y, por ello mismo, las consecuencias que la medida genere no pueden ser absolutas, porque de ser así lo provisorio se convertiría en definitivo y lo probable adquiriría la calidad de certeza" (Casación 718-2013-Callao, publicada en el diario oficial El Peruano medida cautelar no impone un estado el 17 de octubre de 2013).

orientado al cobro de la carta fianza de fiel cumplimiento (N° 220301643-R5).

**TERCERO:** La vigencia de la abstención de ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento (N° 220301643-R5), está sujeta a que TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C acredite la renovación o prórroga de vigencia de la referida carta fianza, mientras dure el arbitraje principal entre TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C y la Entidad.

**CUARTO:** La eficacia de la medida cautelar otorgada a favor de TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C es inmediata desde que sea notificada a las Partes, pero su vigencia se encuentra sujeta a que el Contratista ofrezca dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada con la presente Resolución Cautelar, una contracautela en la modalidad de caución juratoria de cuantía ilimitada en favor de la Entidad, por los daños que eventualmente se produzcan.

**QUINTO:** Se dispone a notificar la presente resolución a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA y a INSUR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, para que tomen conocimiento sobre la medida cautelar otorgada a TERRASOFT CONTRATISTAS S.A.C, y la orden impuesta a la Entidad sobre la abstención de ejecución de la Carta Fianza emitida en el marco del Contrato.

Notifíquese a las partes. -

**RODRIGO ANDRÉS FREITAS CABANILLAS**
Árbitro de Emergencia

**ROSNERY GLADIS DOMINGUEZ QUISPE**
Secretaria Arbitral CÉCARD